

1500419-87.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500419-87.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500419-87.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2039453/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22952531 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

353/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2039453 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 353/22/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CESAR VIANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

BRUNO CESAR VIANA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Notícia o incluso inquérito policial que, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 19h57min, na Rua Irineu Casemiro, nº 33, Parque Abílio Pedro, na cidade e comarca de Limeira, o acusado tinha em depósito, para fins de tráfico, 168 flaconetes contendo cocaína, pesando no total aproximadamente 79 g, e 300 porções

de cocaína, na forma de "crack", pesando no total aproximadamente 46 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado encontrava-se na via pública com entorpecentes no veículo VW Golf, placas DFC8G16, para fins de tráfico.

Policiais militares receberam informação de que havia um indivíduo de camiseta cinza que tinha deixado uma sacola no bairro Abílio Pedro em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Desta forma, os policiais se deslocaram até a Rua Irineu Casemiro, onde encontraram oito indivíduos próximos ao veículo supracitado, sendo que em vistoria no local e busca pessoal nada ilícito foi encontrado.

Entretanto, ao olhar sobre o muro, o cabo Narcizo encontrou a chave de um carro VW e acionou o seu dispositivo, logrando localizar o veículo VW GOLF naquela rua. Em seguida, os policiais retornaram para o grupo de indivíduos abordados e entrevistaram BRUNO, que foi identificado por sua camiseta. O denunciado admitiu que estava na posse do carro e informou que dentro dele havia drogas e dinheiro.

Em busca veicular os policiais encontraram uma sacola preta contendo cinco "kits" de cocaína e sete "kits" de "crack" atrás do banco do passageiro, além de dois "kits" de cocaína e nove flaconetes de cocaína embaixo do banco do motorista. No porta-luvas do carro foi ainda encontrada a quantia de R\$ 1.999,00.

Por fim, foram apreendidos dois aparelhos celulares, sendo um deles encontrado com o denunciado e o outro no interior do carro.

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 99/102).

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 105/106).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes ofereceram memoriais.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 133/138) e da Defesa (fls. 142/156).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo pericial com resultado positivo para "cocaína" (fls. 25/28 e 73/75), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 08).

Em Juízo, o réu disse que tem 35 anos. Trabalha como vendedor. Já teve um bar. No dia da abordagem estava na frente da casa de Lucas. Havia acabado de sair do cabelereiro. Foi receber dinheiro decorrente da venda de um celular, vendeu por

seiscentos reais. Como corta cabelo aproveitou para passar e iria receber. O rapaz dava desculpas que não iria pagar. Já estava no local há quinze minutos. As viaturas chegaram juntas. Havia um pessoal sentado na calçada e a molecada foi abordada. Todos foram abordados juntos. Recusou-se a colocar a mão na cabeça, não fazia nada demais. Achou que iriam ser abordados porque teve uma discussão forte com Lucas. Depois obedeceu a ordem. Explicou o que acontecia, falou que foi cortar cabelo e iria receber o pagamento de Lucas. Tinha algo em seu bolso, era a chave e um celular. Os outros foram questionados. Os policiais foram para a mata e passaram a procurar. Não queria sentar com as mãos no chão. Teve que desbloquear o IPHONE a pedido dos policiais. Os telefones de todos os envolvidos foram verificados. A chave do seu carro ficou na mão dele. Depois de quinze minutos, o policial Narcizo chamou o outro colega de farda e foram até o seu automóvel. Os policiais sabiam que seu carro estava em frente ao cabelereiro. Não foi chamado de imediato para fazer a averiguação do automóvel. Depois eles voltaram, conversaram entre eles, todos foram dispensados. Falou que não tinha drogas no seu automóvel. Desconhecia a existência. Foi colocado contra a parede pelo policial Narcizo. Eles queriam que ele falasse de quem eram as drogas. Foi colocado dentro da viatura. Não tinha drogas no seu automóvel. Foi colocado na calçada. O carro foi aberto, havia um saco preto vazio e foi mostrado a ele. As quatro portas do carro foram abertas e de imediato os policiais foram na gaveta existente no banco e tiraram drogas. Mais entorpecentes foram mostrados a ele. Foi feita averiguação no seu automóvel. No volante havia dinheiro enrolado no elástico. Confirmou que era seu. Não sabia o valor que ali tinha. Foi tudo colocado no saco. No carro tinha três mil e setecentos reais. Fazia sete dias que tinha adquirido o automóvel. O dinheiro era decorrente de uma venda do comércio em sociedade, era de uma venda de um bar. Vendeu o comércio por setenta mil reais. Acredita que as drogas apareceram da mata. Não sabe quem colocou os entorpecentes. Não conhecia os policiais até então (mídia).

Sua versão judicial não convence.

Vejam os teores da prova oral, contrária aos interesses do acusado.

O policial militar Ivan Dias de Jesus disse que, no dia dos fatos, fazia patrulhamento pelo bairro quando foram solicitados por uma pessoa que conduzia uma motocicleta. Essa pessoa disse que passou por uma região de tráfico e viu uma pessoa gorda, alta, trajando camiseta cinza e bermuda deixando uma sacola preta naquele local. O local é ponto conhecido nos meios policiais. Foram fazer averiguação. Adentrou na rua e viram oito pessoas. Todos foram abordados. Entre os que foram abordados estava a pessoa indicada, era o acusado. Em revista pessoal nada localizaram. Fizeram varredura nas imediações e nada localizaram. Seu colega Narcizo, ao vistoriar o muro, achou uma chave de veículo da marca VW. Os abordados foram interpelados. Naquela rua não havia qualquer automóvel daquela marca e ninguém se prontificou a dizer quem era o dono da chave. O cabo Narcizo tentou localizar algum veículo que poderia ser aberto com aquela chave. Na rua traseira seu colega conseguiu destravar o automóvel VW Golf, da cor branca. O cabo retornou e passou a localização do automóvel. Ele viu uma sacola preta no interior do automóvel, sem revista-lo. Interpelaram novamente e foram mais contundentes com relação a Bruno, foi aí que ele assumiu as drogas e o dinheiro que estavam no interior do automóvel. Bruno acompanhou a vistoria e no interior do automóvel seu colega localizou grande quantidade de drogas, prontas para a venda. Também localizaram quantia grande em dinheiro, quase dois mil reais, assim como um celular. Bruno também estava com um celular em seu poder. Não conhecia o acusado até então. Bruno reside em local distante da abordagem. Bruno mencionou que recebia dois mil reais para distribuir drogas naquele local. Quanto aos demais abordados, todos desconheciam a existência daquele veículo Golf, ninguém disse que estava de carro. Estava ele, o cabo Narcizo e um motorista no dia da prisão. Depois chegou outra viatura no apoio. O acusado foi abordado na Rua Irineu Casemiro, nº 33, juntamente com as outras pessoas. Após a localização do veículo na rua é que o réu assumiu ser dono das drogas e do dinheiro. Pela quantidade de dinheiro encontrada

no veículo, acredita que algumas drogas foram vendidas e o dinheiro seria proveniente desse comércio. Havia notas grandes e pequenas, eram variadas. A chave foi encontrada em cima do muro onde os abordados estavam. O cabo Narcizo não foi sozinho ver o automóvel, ele não vistoriou o veículo na primeira vez. Não se recorda de ter salão de cabeleireiro na esquina. Fizeram a pesquisa dos demais abordados. Bruno ficou nervoso quando da abordagem, em especial quando a chave foi encontrada. Os celulares foram apreendidos e encaminhados à perícia. Um celular foi encontrado com Bruno e outro no interior do automóvel. Não encontraram no automóvel anotações de tráfico, não foram na casa do acusado, é que ele assumiu ser dono daquele entorpecente e dinheiro, levaram ele ao distrito policial e encerraram o caso (mídia).

O policial militar Edirlei Aparecido Narcizo disse que, na data dos fatos, por volta das 19 horas, faziam patrulhamento pelo bairro Abílio Pedro. Foram abordados por uma pessoa do sexo masculino que estava numa motocicleta e fez uma denúncia. A denúncia dizia respeito a uma pessoa branca, gorda, alto, com camiseta cinza e bermuda entregando uma sacola preta. O local é conhecido pela traficância. Localizaram oito pessoas. Abordaram todos. Nada de ilícito localizaram. Identificaram o réu com as vestimentas repassadas. Encontraram um celular em seu poder. Fez a busca no perímetro. Em cima do muro achou uma chave de um automóvel VW. Eles foram indagados e ninguém se manifestou. Saiu apertando a chave e na rua detrás, a cerca de cem metros do local, o automóvel piscou. Abriu o automóvel e viu de pronto no banco do passageiro uma sacola preta com kits de drogas. Fechou o carro e retornou. Deu ciência ao comandante. Indagados mais uma vez, Bruno ficou nervoso e foi separado. Foi aí que ele confessou ser dono do automóvel e que ganhava dois mil reais ao mês para distribuir drogas. Uma equipe chegou depois. Com a presença do Bruno fez a vistoria do veículo. No porta-luvas havia grande quantia em dinheiro, em notas diversas, eram quase dois mil reais. Na sacola que já tinha visualizado encontrou 160 porções de cocaína, embaladas em cinco kits diferentes, assim como 300 porções de crack embaladas individualmente. No banco do motorista havia uma gaveta e encontrou mais oito eppendorfs de cocaína. Foi dada voz de prisão. O réu foi abordado na Rua Irineu Casemiro, ele não estava no interior do automóvel. O apoio chegou depois. Foi com outro policial na rua detrás, era de outra equipe. Na primeira vez, não mexeu em nada, ao passar a lanterna viu a sacola contendo drogas. Só na segunda vez é que o acusado assumiu ser dono do veículo, ele ficou nervoso e incomodado com a situação. Em frente ao local há uma área verde, o ponto de tráfico é muito forte, já fez várias prisões naquele endereço. Nunca tinha visto o acusado, não o conhecia, tanto que ele mora em bairro distante. Não havia denúncias envolvendo o acusado, as características físicas e vestimentas foram repassadas naquele dia. Qualificaram os demais envolvidos. Encontraram um celular em poder do réu e outro no automóvel. Os aparelhos foram entregues à autoridade policial, só colocou o número do IMEI na ocorrência do telefone apreendido no automóvel, o outro telefone era IPHONE e o IMEI fica acessível (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o

exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foi ouvida uma testemunha de defesa.

A testemunha Gabriel Gonzaga Ferreira de Freitas disse que é primo do acusado. Foi ouvida como informante. Antes de ser preso, o réu trabalhava na sua loja de móveis planejados, era montador, captação de clientes. O acusado ganhava três mil reais mais cinco por cento das vendas. Antes ele tinha um bar, mas não deu certo e houve a venda para o sócio. O réu tinha um veículo VW Golf e foi comprado com a quantia do bar. Ele não tinha pago qualquer parcela do financiamento. Nunca ficou sabendo do envolvimento do acusado com drogas. Ele nunca havia sido abordado antes pela polícia (mídia).

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares receberam informação que uma pessoa de camiseta cinza havia deixado uma sacola no bairro Abílio Pedro, em local conhecido pela traficância ilícita. Desse modo, os agentes públicos deslocaram-se ao endereço indicado, onde encontraram oito pessoas próximas ao veículo VW Golf.

Ao olhar sobre o muro, o policial Narcizo encontrou a chave do automóvel em questão e acionou o dispositivo. Foi localizado o veículo VW Golf numa rua próxima. Após, os policiais retornaram ao grupo de pessoas abordadas e entrevistaram o acusado, identificado por sua camiseta.

Indagado, o acusado admitiu a posse do automóvel e confirmou a existência de drogas e dinheiro no seu interior.

Em busca veicular, os policiais encontraram uma sacola preta contendo cinco kits de cocaína e sete kits de crack atrás do banco de passageiro, além de dois kits de cocaína e nove flaconetes de cocaína embaixo do banco do motorista. No porta-luvas do carro ainda foi encontrada a quantia de R\$1.999,00. Também foram encontrados dois aparelhos celulares.

Desse modo, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado ao acusado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína e crack), as circunstâncias da prisão, a denúncia anônima e o depoimento incriminador dos policiais militares, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria

devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida (...)”. (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos policiais militares para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Por outro lado, não foram arroladas testemunhas de Defesa que corroborassem a versão do acusado de não ter qualquer envolvimento com a traficância ilícita, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que efetuaram a abordagem e o prenderam em flagrante delito.

É inquestionável que a ação da polícia militar se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

Durante o patrulhamento ostensivo e preventivo, o acusado foi abordado após o recebimento de denúncia anônima apontando as características físicas e vestimentas, em local conhecido pela traficância ilícita, de bairro que ele sequer residia, havendo o encontro de 168 flaconetes de cocaína e 300 porções de crack, além de quantia em dinheiro, circunstâncias estas que somadas geraram a fundada suspeita da posse de objetos ou substâncias ilícitas, que, por sua vez, autorizaram a busca em conformidade com os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.

Nessa direção, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. (...) 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (...)" 6. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo. A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca pessoal. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019).

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, das circunstâncias da prisão em flagrante, existindo depoimento incriminador dos policiais militares.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o

reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância.(...)”.(TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são favoráveis ao réu, devendo a pena-base do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase, observo que o réu foi flagrado com grande quantidade de drogas (168 flaconetes contendo cocaína, pesando no total aproximadamente 79 g, e 300 porções de cocaína, na forma de “crack”, pesando no total aproximadamente 46 g),

não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei.

A quantidade e a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa (cf. STJ, AgRg no HC 668.599/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021; AgRg no REsp 1924209/MG, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, j. 13/04/2021, DJe 26/04/2021).

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão (cocaína e crack), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem: Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional das penas em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração. Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Diante das provas carreadas aos autos (depósito de cocaína e crack no interior do automóvel), declaro o perdimento do veículo VW Golf, placas FDC8G16, em favor da União, que posteriormente será revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, assim como dos demais objetos apreendidos (dinheiro e telefones celulares), porquanto fruto do tráfico ilícito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar BRUNO CESAR VIANA, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) cada do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se não estiver preso em razão de outro processo, por força do regime inicial fixado, incompatível com a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura.

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o HC nº 181.534, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 02/03/2020, "eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de

verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias".

Na mesma direção:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário". (STF, HC 138122, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017).

"HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM O DECRETO PRISIONAL - ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA - A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A PRÓPRIA PENA A QUE FOI CONDENADO - OFENSA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NORTEADORES DE TODA E QUALQUER INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NO CAMPO DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS EM NOSSO PAÍS - "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO". (STF, HC 185087 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 07-10-2020 PUBLIC 08-10-2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. (...) NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (HC 185181 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020).

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do acusado e os demais requisitos do processo de execução.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do veículo VW Golf, placas FDC8G16, assim como dos demais bens apreendidos.

P.R.I.C.

Limeira, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA